

1505756-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... primeiro dia "trabalhando" no local com o tráfico e receberia R\$ 300,00 por dia. Iniciava seu "turno" às 8hs. As drogas estavam na sacola. O réu trazia dinheiro também consigo. Não havia outras pessoas no local. Não sabe informar se o local é ponto de tráfico de drogas, uma vez que não se trata de área de sua Companhia. Não conhecia o abordado anteriormente. Como se vê, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505756-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505756-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064719/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 23470293 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2064719 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS MARTINHO GOIVINHO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

MARCOS MARTINHO GOIVINHO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 08 de março de 2022, por volta das 15h40m, na Rua José da Costa Azevedo, Capital, SP, trazer consigo, com finalidade de traficância e consumo de terceiros, 83 invólucros contendo cocaína, massa líquida de 46,9g, em porções na forma de pó e de "crack", além de R\$ 371,00, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e teve concedida a liberdade provisória com fixação de cautelares (fls. 44/46).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 24 de

maio de 2022.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor do §4º do art. 33, da Lei de Drogas, a fixação de regime aberto, substituição de pena privada de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação preliminar e especialmente pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 69/71, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria do crime também é certa.

Interrogado em Juízo, em sede policial, MARCOS admite a posse das drogas e o exercício da traficância.

Em Juízo, altera sua versão. Nega a prática do delito. Declara que no dia dos fatos foi até um bar comprar uma lata de cerveja. "Cortou" caminho por um "escadão".

Comprou a cerveja e voltava para sua residência. No caminho, avistou de longe uma viatura. Declara que naquela rua há um ponto de drogas. Manteve seu caminhar. Foi abordado e revistado. Próximo de si havia uma sacola. Foi coagido para que

assumisse a posse das drogas. Foi conduzido à Delegacia de Polícia. Não assumiu a traficância. Não admitiu que recebia dinheiro pela prática do crime de drogas. Declara que ficou "um dia inteiro" preso na Delegacia de Polícia. Declara que os

carcereiros o orientaram a negar a prática do crime. Ficou com medo e "admitiu" que policiais encontraram drogas perto dele. Não entendeu que estava sendo "processado" como traficante. Alega que não sabe o que constou de sua versão em Delegacia de Polícia.

A versão do acusado em Juízo, além de contrariar aquela declinada em Delegacia de Polícia, foi infirmada pelas demais provas orais colhidas em audiência de instrução.

Consigno, de plano, que ambos os policiais inquiridos em audiência como testemunham relatam a ocorrência de maneira coincidente e detalhada no que diz respeito às circunstâncias da prisão em flagrante do réu.

Segundo a testemunha Alexandre Nobre, policial militar, no dia dos fatos realizavam patrulhamento quando avistaram o réu portando uma sacola próximo a um escadão. Era uma sacola preta. O réu, indagado sobre o que havia dentro da sacola, disse que trazia entorpecentes. Constataram que, de fato, a bolsa tinha drogas em seu interior. O réu declarou que era o primeiro dia que exercia a traficância. Que havia começado a "trabalhar" por volta das 08 da manhã. Havia cocaína e crack na bolsa. Também foi apreendida uma quantia, aproximadamente R\$ 370,00, decorrente da traficância. Não havia outras pessoas no local – o abordado estava sozinho. Não se recorda se o abordado declinou condição de usuário. Trabalha há pouco tempo naquela região. Não tem conhecimento se o local era ponto de tráfico. Reitera que não havia outros indivíduos no local e a sacola era trazida pelo abordado. Quando abordado, os policiais pediram que ele deixasse a bolsa no chão, durante a revista pessoal. Não conhecia anteriormente a pessoa abordada, ora acusado.

A testemunha Michel Alisson, também policial militar, relata que no dia dos fatos realizava patrulhamento quando avistaram um indivíduo na posse de uma sacola preta. Ao notar a aproximação policial, o indivíduo demonstrou nervosismo. Realizada a abordagem, o indivíduo de plano já admitiu que tinha drogas sob sua posse. Ainda,

disse que era o seu primeiro dia “trabalhando” no local com o tráfico e receberia R\$ 300,00 por dia. Iniciava seu “turno” às 8hs. As drogas estavam na sacola. O réu trazia dinheiro também consigo. Não havia outras pessoas no local. Não sabe informar se o local é ponto de tráfico de drogas, uma vez que não se trata de área de sua Companhia. Não conhecia o abordado anteriormente.

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares contrariam a narrativa apresentada pelo acusado em Juízo, e ambos relatam, de maneira uníssona, não só que o réu portava a bolsa em cujo interior foram localizados as porções de entorpecentes, mas também que o abordado, ora acusado, admitiu que estava no local exercendo a traficância.

Consigna-se que os policiais militares não conheciam o flagranciado anteriormente, inexistindo motivos para que seus depoimentos sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas. Aliás, não só aos policiais militares, mas também à Delegada de Polícia responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante o réu sugere que teria injustamente o incriminado, ao lançar no termo de declarações uma falsa confissão do crime pelo flagranciado.

Ao que parece, o acusado lança mão de versão para colocar em xeque as condutas de todos os agentes públicos, de órgãos e cargos públicos diferentes, que de alguma forma estiveram vinculados à ocorrência. Conforme exposto, entretanto, nada há nos autos de concreto que indique a ilegitimidade, ainda que mínima, da postura desses agentes públicos.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância. Com efeito, foram apreendidos 83 invólucros contendo cocaína, massa líquida de 46,9g, em porções na forma de pó e de “crack”, além de R\$ 371,00 com o réu, quantia essa compatível com os valores recebidos diariamente por traficantes em situação análoga à do abordado, o que torna inequívoca, também pela quantidade não ínfima e pela maneira fracionada como estavam acondicionadas, a finalidade de comércio ilícito. Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor a condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao acusado. Quanto à preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06 e sua utilização necessária na primeira fase de dosimetria, verifico que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, revisitando parte dos temas debatidos no REsp 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 1º/7/2021), decidiu por manter o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base ou para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos (AgRg no HC 685.184/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021). E tal entendimento foi confirmado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 725.534/SP, ocorrido em 27/4/2022, fixando-se a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena (Informativo do STJ n. 734, de 2 de maio de 2022).

Submeto, portanto, no caso concreto, a avaliação da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos para a terceira fase de dosimetria, evitando, em última análise, uma dupla valoração e o bis in idem, e estabeleço a pena base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes. Fica mantida a pena, nesta segunda fase, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena. Primário, sem anotações na Vara da Infância e Juventude e não havendo nos autos outros elementos

concretos, além da quantidade de drogas, a evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas, considero comportar a incidência do redutor previsto no parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. Autorizada, conforme exposto no julgamento do HC 725.534/SP, a modulação pela quantidade e natureza dos entorpecentes nesta terceira fase, verifico que se trata de apreensão de 83 invólucros contendo cocaína, massa líquida de 46,9g, em porções na forma de pó e de "crack", a justificar a incidência do redutor em fração que reputo proporcional em 1/2. Operada a diminuição, fica a pena estabelecida em definitivo em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, adiro à recomendação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 596.603-SP e, sendo a pena inferior a quatro anos de reclusão, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena. Ainda, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade assistencial, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, no valor de um salário-mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu MARCOS MARTINHO GOIVINHO JUNIOR às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, esses no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade e prestação pecuniária em favor de entidade assistencial, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, no valor de um salário-mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Concedida a liberdade provisória durante a instrução e estabelecida pena em regime aberto com substituição por restritivas de direitos, faculto o recurso em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, dos objetos e valores apreendidos nos autos e relacionados no auto de exibição e apreensão. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA